

1522055-94.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Assim, as provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522055-94.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522055-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO ROLLANO VEDIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

FRANCISCO ROLLANO VEDIA, foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de setembro de 2022, por volta de 18h30, na Rua Eduardo Chaves, nº 43, Bom Retiro, nesta cidade e Comarca da Capital, guardava, e trazia consigo droga, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 06 embalagens plásticas ("tijolos") contendo 6,15 Kg (seis quilos e cento e cinquenta gramas) de cocaína.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 17.

Laudos periciais a fls. 62/70.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, bom consignar que descabe ao magistrado impor ao órgão do Ministério Público contratar com o acionado o ANPP, sem amparo na Lei.

Ao oferecer a denúncia a representante Ministerial apresentou seus motivos, negando a oportunidade do ANPP (fls. 81, item 5).

Citado, o acionado apresentou resposta escrita, sede em que silenciou, inclusive, quanto a oportunidade conferida pelo art. 28-A, § 14, do CPP.

Logo, a este momento, descabe qualquer outra providência, máxime porque, consoante coloquei acima, como equidistante das partes, num processo acusatório, descabe ao magistrado interferir na esfera de disposição das partes para ajuste.

Como o magistrado não pode impor a qualquer acionado aceitar um benefício eventualmente proposto pelo órgão de Acusação, não pode, também, impor ao órgão de Acusação oferecer benesse, principalmente da espécie negócio jurídico de natureza extrajudicial.

Muito menos, ainda, substituir-se à figura do Ministério Público.

Sobre o tema, confira-se: A ordem não pode ser concedida. O Acordo de Não Persecução Penal ANPP, instituído no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.964/19, popularmente conhecido como “Pacote Anticrime”, é prerrogativa do Ministério Público, conforme expressamente dispõe o caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos nossos): “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”: O mesmo dispositivo processual penal prevê, no § 14: “§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. A possibilidade de interferência do Judiciário nessa prerrogativa é bastante limitada, prevista nos §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, do mesmo art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos nossos): “§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. § 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia”. Como o Acordo de Não Persecução Penal ANPP foi negado pelas duas instâncias do Ministério Público, não há possibilidade legal de intervenção do Poder Judiciário nesse tema, o qual, volto a frisar, é prerrogativa da Justiça Pública. No mais, não se vislumbra nos autos qualquer constrangimento passível de ser corrigido por meio do remédio heroico. Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem. (Habeas Corpus Criminal nº 2058982-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de maio de 2020, rel. Desembargador CAMILO LÉLLIS); Pois bem. Em prelúdio, como frisado pelo Ministério Público que atua no Juízo a quo, e nos exatos termos da lei, deve o MP entender que o acordo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o que não restou configurado no caso em tela. Conforme lição de Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal, 8ª edição, 2020, Editora Juspodivm, o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso (devidamente assistido por seu defensor), o qual confessa formal e circunstancialmente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do parquet de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não

oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. Dessa forma, deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. Ademais, o legislador previu no art. 28-A, §14, que diante da negativa do Ministério Público em oferecer o referido acordo, pode o magistrado remeter os autos ao i. Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP, o que de fato foi feito nestes autos, conforme podemos verificar às fls. 35/41. No entanto, o digno Procurador Geral de Justiça manteve a posição do Promotor de primeiro grau e insistiu na recusa de oferta do referido acordo. Logo, todas as medidas possíveis ao Poder Judiciário foram tomadas para eventual realização do referido acordo, não sendo possível exigir que o Ministério Público o ofereça após a confirmação da recusa por seu órgão máximo. Com efeito, cabe observar que com o Estatuto Anticrime o nosso ordenamento processual penal deu uma inquestionável guinada no sentido do sistema acusatório puro, colocando o juiz em posição menos interferente no que toca à formulação da acusação. Ou seja, o juiz até pode aplicar o art. 28 do CPP por força do disposto no parágrafo 14 do novo art. 28-A, mas não pode, em sendo mantida a recusa do MP, ir além disso, até porque, se bem observada a nova redação do art. 28 (também por força da Lei 13.964/19 Estatuto Anticrime), o órgão do MP nem mais submete ao juiz a apreciação da sua ordem de arquivamento. Tanto é assim que já há precedentes neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o Poder Judiciário deve se abster de interferir na questão, conforme podemos observar do acórdão proferido pela 15ª Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus 2026314-51.2020.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des. Ricardo Sale Júnior: Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28 A do Código de Processo Penal dispõe que: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...). Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2026314-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2020; Data de Registro: 05/04/2020). Acresça-se que o reconhecimento da causa de diminuição de pena no delito de tráfico (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) impõe na maioria das vezes que haja o processo e dilação probatória para a constatação de todos os seus requisitos, o que, por si só, afastaria o ANPP pois se trata de forma de resolução penal pactuada pré-processual. Enfim, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM. (Habeas Corpus Criminal nº 2075422-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de maio de 2020, rel. Desembargador XISTO RANGEL); E circunscrita a competência do Poder Judiciário à análise da legalidade do oferecimento, ou não, da proposta de ANPP, conclui-se que o ato atacado não está maculado de ilegalidade, eis que de modo correto e adequado verificou a formalidade legal do não oferecimento, pelo Ministério Público, da proposta de acordo de não persecução penal que, como visto, está condizente com a disciplina legal acerca do instituto. Não há, por isso, que se reconhecer ilegalidade e nulidade no feito em face da não apresentação de acordo de não persecução penal. Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP SP. Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem. (Habeas Corpus Criminal nº 2062921-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de abril de 2020, Desembargador KLAUS MARQUELLI ARROYO)

No mesmo sentido: Habeas Corpus Criminal nº 2043590- 95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j.

em 22 de abril de 2020, rel. Desembargador NEWTON NEVES; Habeas Corpus Criminal nº 2048237-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 17 de abril de 2020, rel. FRANÇA CARVALHO.

Afastada a questão preliminar, ao mérito, o que verdadeiramente interessa.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17, e Laudos Periciais de fls. 62/70, onde se infere que o material apreendido com o acionado, se tratava, efetivamente, de substância entorpecentes, no caso, cocaína.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na guarda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado não deu muita explicação, somente alegando estar arrependido (Fls. 08/09).

Em audiência, confessou a prática criminoso, admitindo que, a mando de terceiro, teria que fazer entrega do pacote a outra pessoa, sabendo que transportava drogas, justificando sua conduta sob o prisma da necessidade, certo, neste ponto, que suas necessidades pessoais não justificam, à evidência, que se preste a transportar drogas, em grande volume, e de qualidade altamente viciante.

Triste postura!

Doutro lado, o restante da prova, encimado nos relatos precisos e harmônicos dos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Fabiano Aparecido Gasparoto e Marcello Barrozo Soubihe narraram, em depoimentos absolutamente harmônicos, à semelhança do informado na fase policial, que na ocasião dos fatos, estavam realizando diligências de campo visando dar continuidade a trabalhos investigativos que resultaram na prisão em flagrante de três cidadãos estrangeiros envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Indicaram ter conhecimento de que um bar localizado no local dos fatos estava sendo utilizado por estrangeiros como ponto de distribuição de drogas. Diante de tais informações, passaram a realizar empenhos velados na referida região, monitorando à distância a entrada e saída de pessoas no citado estabelecimento comercial. Na data dos fatos, então, enquanto realizavam a campana, notaram a entrada de um casal com uma criança, ambos aparentando ser estrangeiros, dadas as características físicas, certo que o varão levava consigo uma sacola plástica na cor preta, contendo aparentemente uma caixa dentro, tendo o casal se sentado em uma das mesas, o homem colocado a sacola que levava entre suas pernas. Diante de tais circunstâncias, resolveram verificar. Feita a abordagem ao casal, o acionado sendo o varão, com ele localizaram, no interior daquela sacola que trazia em meio às pernas, seis tabletes de substância que, por suas características, assemelhava-se a "cocaína". Questionado, o acionado alegou não se comunicar bem em português, nada dizendo acerca dos entorpecentes. Indicaram, ainda, que a virago que o acompanhava presenciou o encontro do entorpecente, afirmando que somente o acompanhava ao local.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo drogas, para evidente entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, consistentes em 06 embalagens plásticas ("tijolos") contendo 6,15 Kg (seis quilos e cento e cinquenta gramas) de cocaína, drogas estas marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como dadas as circunstâncias absolutamente suspeitas em que as drogas foram localizadas.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado, máxime porque os policiais simplesmente confirmaram a própria confissão do acionado.

Ademais, para a prisão, os policiais não são obrigados a conclamar testemunhas civis, valendo de nota que, na espécie, a acompanhante do acionado presenciou a apreensão das drogas, sendo ouvida na fase policial (fls. 07), ela que não arrolada

pela Defesa a informar o contrário em Juízo.

Insta consignar, porque oportuno, que os policiais civis, conforme narraram, já estavam em trabalho de investigação, especificamente acerca do transporte de entorpecentes na região, realizado por pessoas de origem latina, de sorte que o acionado, cuja fisionomia latina não se há de negar, trazia consigo no local investigado uma sacola aparentemente pesada, o que levantou séria suspeita a determinar a necessidade de averiguação.

Com efeito, o disposto no art. 5º, inciso X, da Carta da República, não se mostra, tampouco pode se mostrar, como um salvo conduto para práticas criminosas.

Qual nulidade na abordagem? Óbvio que nenhuma, realizada nos limites da Lei (art. 244, do CPP), e da proteção da sociedade.

Ora, como bem claro na prova, houve fundada suspeita aos policiais para a realização da abordagem e vistoria.

Ou seja, absolutamente legal a conduta dos policiais, donde decorre farto material probatório lícito para indicar a responsabilidade do acionado pela prática do crime de tráfico de drogas em larga escala.

Importante destacar, ainda, que a ação policial efetuada nesse caso não pode ser considerada ilegal, simplesmente porque o acionado estava em situação de flagrante de delito permanente. E, como se sabe, a situação de flagrante permanente, tal como se dá nos casos de delito de tráfico de drogas, dispensa a apresentação de mandado judicial de busca, na esteira do que preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigos 242 e 244, ambos do Código Penal (Habeas Corpus Criminal nº 2267082-98.2021.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 14 de janeiro de 2022, rel. Desembargador FREITAS FILHO).

Neste sentido, ainda: Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, não se verifica qualquer em ilicitude de provas colhidas por suposta ausência de fundadas razões para a revista pessoal. Como restou demonstrado, os policiais agiram dentro dos parâmetros legais. O réu demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial, pelo que legítima a abordagem, que culminou com a apreensão de drogas descritas na denúncia. Legitimou-se a prisão em flagrante delito porque o réu estava na posse de dinheiro, indicou o local em que se encontrava as drogas, justamente sob uma telha, defronte à sua pessoa. Assim, evidenciado que a busca pessoal foi em decorrência de cumprimento de obrigação constitucional e legal dos policiais, fundada na suspeita apresentada pelo réu. Veja-se que o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal é claro em sua redação, ao exigir que a busca pessoal seja realizada quando houver fundada suspeita da posse dos objetos ali arrolados: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. Evidente que a conduta do acusado ao se demonstrar desconfortável com a presença da polícia no local se releva como hipótese de fundada suspeita. Nesse sentido, a doutrina ensina que a fundada suspeita: “é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente.” (in NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 556 grifos nossos). Deste modo, nenhuma nulidade há de ser declarada, ficando afastada a preliminar aventada (Apelação Criminal nº 1506370-81.2021.8.26.0228, da Comarca de São Paulo,

7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 29 de setembro de 2021, rel. Desembargador FERNANDO SIMÃO).

Doutro giro, a alegação de quebra da cadeia de custódia, no caso em apreço, vem lançada sem muito compromisso, não merecendo aceitação.

No momento do flagrante delito se identificou a potencialidade do material apreendido com o acionado como sendo drogas, então, de interesse para a prova (artigo 158-B, I, CPP). Daí, se procedeu à coleta, transporte e recebimento do material na sede da Polícia Civil (artigo 158-B, IV, V, VI e VII do CPP), consoante se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 17.

Encaminhado o material à perícia, sobrevieram os laudos periciais de fls. 62/70, a que a Defesa teve pleno acesso.

Por isso, nenhum prejuízo concreto foi demonstrado pela combativa Defesa, o que afasta a alegação de nulidade dos autos.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

No mesmo sentido: Apelação Criminal nº 0008556-74.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, j. em 7 de dezembro de 2021, rel. Desembargador CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.

Prossigo, então.

A enorme quantidade de drogas apreendidas, num total 06 embalagens plásticas ("tijolos") contendo 6,15 Kg (seis quilos e cento e cinquenta gramas) de cocaína, substância altamente lesiva, as circunstâncias do flagrante, tendo sido localizadas as drogas no colo do acionado, os depoimentos firmes dos policiais que os abordaram, conjugados com a própria confissão do acionado, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis ao agente.

De início, impressiona o elevado volume de drogas, mais de seis quilos, da potente cocaína, substância de natureza altamente lesiva, de maneira que, considerando tais circunstâncias do caso concreto, absolutamente desabonadoras, de rigor a fixação das penas base em patamar proporcionalmente superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Destarte, estabeleço suas penas base no cumprimento de pena privativa de liberdade de oito anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a oitocentos dias multa.

Em segunda fase, ausentes agravantes.

Doutro lado, presente a atenuante da confissão, o que me leva a reduzir suas reprimendas ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a seiscentos dias multa.

Em terceira etapa, não existem causas de aumento ou de diminuição de penas.

Inviável, na espécie, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, na medida em que ausentes os requisitos legais, que são cumulativos, para tanto.

Eis a letra da lei: Art. 33. (...). § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ora, em que pese primário, é evidente que não se pode concluir que alguém participe do transporte de elevadíssimo volume de entorpecentes, ainda a ser partilhado para entrega ao mercado de consumo de massa, não se dedique a atividades criminosas ou mesmo não tenha ligação com alguma organização criminosa.

Nesta toada, é importante recordar a ratio essendi do privilégio previsto na norma em comento, qual seja, beneficiar o denominado pequeno traficante, aquele que de maneira absolutamente primária e "amadora" acabou se deixando levar por caminhos escusos à prática da mercancia ilícita de pequeno vulto, fazendo com que não ingresse no sistema prisional e lá tenha contato com criminosos de maior envergadura, o que poderia, ao invés de afastá-lo do crime, introduzi-lo ainda mais no meio espúrio.

Não obstante, no caso dos autos não se está diante do denominado "pequeno traficante", na medida em que, frise-se, localizada vultosa quantidade de droga cocaína, o que indica evidente ligação com organização criminosa, ou, ao menos, dedicação a atividades ilícitas bastante a lhe gerar a confiança necessária para que participasse ativamente daquela ação de transporte da droga, em volume alentado, a mando de terceiro, para posterior distribuição.

Importante anotar que o fato de a vasta quantidade de entorpecentes ter sido considerada em primeira etapa da dosimetria para elevar a pena base, não prejudica a consideração desta mesma circunstância para que se entenda que o acusado FRANCISCO dedica-se a atividades criminosas e integre organização criminosa, impedindo a aplicação do mencionado redutor.

Não há se falar em "bis in idem", na medida em que não é a quantidade das drogas que está a impedir a aplicação do benefício, mas sim o fato de o réu dedicar-se a atividades espúrias, conclusão esta que se chega, aí sim, através do primeiro fato comprovado.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria: TRÁFICO. Quantidade expressiva. Apreensão de 537,49 gramas de cocaína com jovem de 19 anos e 4 meses de idade, e sete anotações na Vara da Inf. e Juventude, pese ainda criminalmente primário. Alguém que não estuda, não provou existência de economia suficiente para posse de tamanha quantidade de estupefacientes. Quadro de circunstâncias que conduzem à vinculação ao tráfico organizado. Provido o recurso ministerial para agravar a reprimenda, desprovido o defensivo, com base em farta e recentíssima jurisprudência do e. STJ. (...) Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas apreendidas (2,206 kg de cocaína), elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstra que aquele paciente se dedicava às atividades criminosas. Noutras palavras, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos possa ser utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a reprimenda de piso, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, conseqüentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. E isso porque, "de acordo com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há 'bis in idem' quando a quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas, sim, como fator impeditivo de seu reconhecimento, por indicar que o agravante fazia do tráfico ilícito de drogas seu meio de vida" (AgRg no REsp 1.580.686/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 01/02/2017). É o que ora fazemos. Certo é que "A col. Suprema Corte preocupou-se em evitar a dupla valoração

da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e na definição do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (...) Na hipótese, a majoração da pena base está fundada na quantidade de drogas apreendidas, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem" (STJ, HC 483.227/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 19/03/2019).

A orientação foi repetida por ocasião do julgamento, ainda no e. STJ, do AgRg no HC 472.650/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26.2.2019: "(...) Hipótese em que a Corte de origem sopesou validamente a quantidade e a natureza da droga apreendida (1,05 kg de cocaína) na primeira etapa da dosimetria penal, para exasperar a pena-base em 6 meses de reclusão, e na terceira fase, para justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que tais vetores indicam a habitualidade delitiva da agravante".

Ora, é absolutamente inviável se entender que determinada pessoa foi presa transportando mais de seis quilos de drogas, cujo valor é absolutamente expressivo, e que esta mesma pessoa, por outro lado, não tem qualquer envolvimento com o crime organizado ou com atividades criminosas.

Desta forma, inaplicável o privilégio, sempre respeitado entendimento contrário.

Penas finais: o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa.

O sentenciado FRANCISCO cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta.

Absolutamente incabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, tendo em vista que aquela excede a quatro anos, bem como em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado, considerada em primeira etapa da dosimetria.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu FRANCISCO ROLLANO VEDIA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a seiscentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis, ainda, os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, de forma que mantenho a custódia do condenado, caso queira recorrer, mormente agora, o sentenciado tendo recebido duras penas, o que ressoa evidente que, caso em liberdade, não irá se colocar voluntariamente, no futuro, a seu cumprimento.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, transferindo-se o valor depositado a fls. 73 ao FUNAD.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06